

1500530-10.2021.8.26.0481

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500530-10.2021.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500530-10.2021.8.26.0481 - Feito nº 2021/001387

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK DA SILVA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2173610/2021, ofereceu denúncia em face de PATRICK DA SILVA SOUZA, devidamente qualificado às fls. 24, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 28/06/2021, por volta das 03h00, na Rodovia Raposo Tavares, Km 654, nessa cidade e Comarca, PATRICK DA SILVA SOUZA estaria transportando, para entrega a consumo de terceiros, quatro porções de haxixe, pesando aproximadamente 1.012 gramas, droga capaz de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que o delito teria sido cometido no interior de um ônibus de passageiros da "viação Motta" e que os entorpecentes estariam sendo transportados do estado do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo.

Dispensada a realização da audiência de custódia com fundamento no comunicado CG nº 250/2020, no supramencionado artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62/2020 e no Provimento CSM nº 2.549/2020, que estabeleceu o Sistema Remoto de Trabalho em virtude da pandemia de covid-19, o Ministério Público, em manifestação, pugnou pela homologação da prisão em flagrante e pela sua conversão em prisão preventiva (fls. 47-51).

A N. Defesa, por seu turno, postulou pelo relaxamento da prisão em flagrante e,

subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória ao acusado (fls. 55-72). Homologado o auto de prisão em flagrante, foi convertida a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva na data de 28/06/2021 (fls. 75-84).

Laudo de exame químico de entorpecente acostado (fls. 114-116).

O acusado foi notificado (fls. 133) e, nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, com a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, e do Comunicado CG nº 2063/2021 que determinou o cumprimento do item "a" da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, de relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, foi revisada e mantida sua prisão cautelar (fls. 144-146 e 156-157).

Decorrido em branco o prazo para apresentação de defesa prévia, destituiu-se o advogado dativo nomeado às fls. 53 (fls. 223).

Defesa prévia (fls. 241-244).

A denúncia foi recebida em 25/11/2021, ocasião em que foi rejeitada a hipótese de absolvição sumária e, considerando a gravidade da situação, em virtude da pandemia de COVID-19 e das recomendações dos órgãos de saúde pública para o máximo isolamento social, a fim de se prevenir a propagação do contágio e visando resguardar a saúde dos presentes, com fundamento no comunicado CG nº 250/2020, no artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62/2020, em caráter excepcional, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 245-248).

O réu foi regularmente citado (fls. 262).

Prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A defesa pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de PATRICK DA SILVA SOUZA pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 33, caput, e artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 05-06), boletim de ocorrência (fls. 07-11), auto de exibição e apreensão (fls. 17), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 18), laudo realizado no aparelho celular do acusado (fls. 161-222) e laudo pericial químico de entorpecente (fls. 114-116), que atestou que a substância detectada se tratava de Tetrahidrocannabinol (THC), que é de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é incontestada, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado Patrick da Silva Souza.

O policial militar rodoviário DANILO MARTINS PESENTE, após regular compromisso, declarou em audiência de instrução, debates e julgamento que: "Correto. O fato ocorreu no dia 28, porém, preciso explicar os fatos acontecidos no dia 25. Dias antes, tinha sido feita uma abordagem no Patrick em Eptácio. Ele estava perto da rodoviária e trazia documentos pessoais, mala vazia e um pouco de dinheiro. Sua atitude causou estranheza. Por isso, fomos abordá-lo: em entrevista, ele nos disse que era de Belo Horizonte e estava indo até Ponta Porã, onde ficaria por uns dias na casa de uma tia. Achemos estranho, arrolamos seu nome e o liberamos para seguir viagem. A partir de então, começamos a monitorar as linhas de ônibus que fazem o itinerário Ponta Porã - Belo Horizonte. Nesse dia 28, logramos êxito em encontrar seu nome como passageiro. Então, ficamos aguardando o ônibus entrar no estado de São Paulo e fizemos a abordagem ali na divisa: ele estava com a mesma mala que portava dias antes. Ela estava no porta-malas externo do ônibus; o cachorro sentiu cheiro de algo ilícito ali e nos apontou; abrimos a mala, onde estavam roupas femininas e itens que não condiziam com ele; no fundo falso da mala foram encontrados tabletas de haxixe. Fomos conversar com ele que, de pronto, confessou

ter pegado as drogas em Ponta Porã de um desconhecido e as levaria até Belo Horizonte, onde as entregaria também a terceiro desconhecido e pelo serviço ganharia R\$ 10.000,00".

Depoimento corroborado na íntegra por seu colega de farda, o senhor LUIZ GUSTAVO CARVALHO SARTI, ouvido nas mesmas condições, que apenas acrescentou que:

"Excelência, tínhamos abordado e entrevistado Patrick uns dias antes. Ele alegava que estaria indo visitar uma tia em Ponta Porã e logo voltaria a Belo Horizonte. Pelas contradições nos depoimentos, começamos a monitorá-lo a partir de seus dados pessoais; pedimos apoio do canil e o encontramos em um ônibus vindo do Mato Grosso do Sul. No dia da abordagem, o motorista disse que as malas em que o cachorro teria encontrado os quatro tabletes de haxixe eram de Patrick – em entrevista com o suspeito, ele admitiu ter pegado as drogas de um desconhecido em Ponta Porã e as entregaria a terceiro desconhecido em Belo Horizonte. Pelo serviço, ganharia R\$ 10.000,00".

O acusado foi advertido sobre o direito ao silêncio. Após entrevista reservada com sua advogada, assim exerceu sua autodefesa: "Eu gostaria de falar sim. Eu tinha recebido a proposta lá quando tinha acabado de ser demitido do serviço, entendeu? E precisava de dinheiro para pagar contas de luz, água e comprar uns negócios para minha filha, lá em Belo Horizonte. Fui lá, vi que a proposta era boa e vim, mas se eu soubesse que ia dar isso tudo, nem teria saído de casa. Lá eu trabalhava como serralheiro, mas, por causa da pandemia, os trabalhos ficaram muito difíceis e meu patrão me mandou embora, porque a loja estava sem movimento. Estava difícil de arrumar bico ou serviço e aceitei a proposta. Também referente a minha filha, que precisava comprar as coisas para ela. Seis anos, agora ela deve estar ou com a minha mãe ou com a mãe dela. Eu tinha deixado ela com a mãe dela (já antes de ser preso). Sim (confirma que a criança morava com a mãe antes mesmo dele ser preso). Eu já tive lá em Belo Horizonte, foi usuário e incêndio. Eu usava de vez em quando lá na rua. Não".

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em consonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas policiais militares que empreenderam as investigações e efetuararam a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Todavia, vale consignar que "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância", nos moldes delineados do artigo 197 do Código de Processo Penal.

De outro lado, por tudo que foi coligido durante a persecução criminal, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas. Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Com relação à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, consigno que resultou devidamente caracterizada, visto que o bilhete juntado a fls. 16 c/c fls. 34 comprova que o acusado estava sendo transportado na linha Campo Grande-MS – Belo Horizonte-MG.

Ademais, a prova oral colhida é harmônica e convincente no sentido de que

efetivamente o réu foi preso enquanto transportava haxixe entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Quanto à causa de aumento do inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, entendo que o fato de o réu utilizar meio de transporte público para transportar a droga não implica a causa de aumento de pena, uma vez que a causa de aumento de pena se aplica apenas caso a comercialização ocorra dentro do transporte público, o que não é o caso dos autos.

Nesse aspecto:

TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – TRANSPORTE PÚBLICO. O que previsto no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, relativamente ao transporte público, pressupõe o tráfico no respectivo âmbito, e não a simples locomoção do detentor da droga. (STF – HC: 122042, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 23-10-2017 PUBLIC 24-10-2017).

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irreabilidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado.

As testemunhas de acusação descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos, de forma que, tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos.

A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a grande quantidade de entorpecente (1.012 gramas de haxixe); o modo de acondicionamento (quatro grandes porções, capazes de gerar, ao menos, 506 porções individuais, considerando que uma porção de haxixe contém, em média, de um a dois gramas); a tentativa de ocultação do entorpecente; o local onde se deram os fatos (divisa dos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, conhecida rota de tráfico de entorpecentes oriundos do Paraguai, no interior de transporte público coletivo); a confissão informal do réu aos policiais que o prenderam, reiterada tanto em sede policial quanto em juízo; o laudo pericial do aparelho de telefone celular do acusado, que expõe diversas fotografias e diálogos indicativos da prática do tráfico de entorpecentes (fls. 193-222), revelam que se tratava mesmo da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis. Isso porque deixo de considerar, nesta fase de dosimetria, a fim de evitar “bis in idem”, os critérios constantes do artigo 42, da Lei de 11.343/06, uma vez que tais circunstâncias serão consideradas na terceira fase de dosimetria.

Nesse sentido:

"[...] a Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, ainda, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza, o *bis in idem*. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder de discricionariedade, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de *bis in idem*" (STF – HC: 121853 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: Dje-213 DIVULG 29-10-2014).

Destarte, considerando que não ostenta o réu maus antecedentes criminais e que todos os demais elementos são inerentes ao tipo penal, fixo as penas no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, encontra-se presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP). No entanto, mantenho as penas anteriormente fixadas, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de cálculo penal, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovado, conforme já exarado, o cometimento do delito entre Estados da Federação. Assim, aumento em 1/6 as penas, obtendo-se, como resultado, o total de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Todavia, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa. No entanto, verifico que o acusado foi flagrado transportando alta quantidade de entorpecentes, o que impõe a redução no patamar de 1/2, totalizando 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 291 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, excepcionalmente, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade, conduta social, personalidade favoráveis e, ainda, por ter confessado integralmente a prática delitiva e ter mostrado grande arrependimento, não obstante a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de

liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser corrigida monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR PATRICK DA SILVA SOUZA, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade; e prestação pecuniária em favor de instituição pública ou privada de destinação social no montante de um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Observando-se o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobretudo pela quantidade de reprimenda corporal aplicada e porque ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Concedo ao sentenciado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita.

Considerando que foram apreendidos nos autos um aparelho celular (auto de exibição e apreensão de fls. 16), o qual está diretamente relacionado à prática delitiva, declaro o seu perdimento em favor da União e autorizo a destruição do bem, dada à inexpressividade de seu valor econômico.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente remanescente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se o órgão competente para o recolhimento do bem apreendido, de acordo com artigo 63, § 2º, da Lei 11.343/06;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) sentenciado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

de Presidente Epitácio, 05 de maio de 2022

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.